

1501132-12.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto. É o sentir da jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio

- Desclassificação para uso inadmissível. (TJSP - AC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501132-12.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501132-12.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2128489/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 17853565 - DEL.POL.JANDIRA, 955/2021 -

DEL.POL.JANDIRA, 2128489 - DEL.POL.JANDIRA, 955/21/408 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SABA KELSE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Vinicius Sabá Kelse, menor de 21 anos à data do fato, qualificado e interrogado administrativamente à fl. 13, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ou seja, tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, em 11 de maio de 2021, por volta de 16h30min, os policiais militares Renan Vinicius de Souza Soares da Silva e Anderson Caffé Barbosa deslocaram-se até a Rua dos Melos, nº 154, Vila Eunice, no município de Jandira, e identificaram a casa com o número referido pelo noticiante.

Segundo apurado, os militares aproximaram-se da residência e chamaram pelo nome "Vinicius", sendo que o acusado atendeu e dirigiu-se até o portão, informando aos policiais que retornaria ao interior da casa para apanhar a chave. Entretanto, Vinicius foi lançar pela janela uma caixa de papelão que veio a cair no imóvel sozinho. Ao verificar o conteúdo da caixa, os policiais localizaram 5 porções de maconha, com peso líquido de 31,23 gramas, além da quantia em dinheiro no total de R\$214,00.

Após retornar para abrir o portão, o acusado foi questionado pelos policiais acerca da caixa, tendo confessado a prática da traficância, motivo pelo qual ele foi imediatamente preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Em poder dele também fora apreendido um celular da marca Apple, modelo Iphone 11. Formalmente interrogado pela Autoridade Policial, o acusado que ostenta passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude (por atos análogos a roubo e furto - fl. 29), optou por permanecer em silêncio (fl. 13).

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-04.

Auto de exibição e apreensão acostado à fl. 06.

Auto de prisão em flagrante delito acostado à fl. 10.

Folha de antecedentes - fls. 27-28.

Certidão criminal - fls. 29-30.

Requerimento de concessão de liberdade provisória acostado às fls. 37-44.

Declaração de referência profissional e idoneidade moral acostada às fls. 47-48, 50 e 52).

Laudo pericial de constatação preliminar acostado às fls. 58-60.

Manifestação do Ministério Público requerendo que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva acostada às fls. 61-62.

Decisão judicial concedendo ao réu o benefício da liberdade provisória, aplicando-se cumulativamente as medidas cautelares de praxe do juízo acostada às fls. 63-68.

Alvará de soltura acostado às fls. 69-70.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 95-96.

Denúncia oferecida às fls. 101-103.

Denúncia recebida às fls. 104-106.

Citado o réu (fl. 116), por meio de advogado constituído (fl. 119), apresentou resposta à acusação às fls. 120-130.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais escritos pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de nulidade alegada pela defesa, notadamente pelo fato de ser pacífico o entendimento de que eventual nulidade de atos inquisitoriais não afetam a ação penal. Ademais, não há nenhum indício a sedimentar a tese aventada de vício nos depoimento colhidos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CPP. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial". (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1277345/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018)

Também, sustenta o réu a nulidade das provas em razão de a busca e apreensão ter ocorrido sem mandado judicial. Todavia, resta sedimento pela Corte Suprema acerca da desnecessidade de ordem judicial para o cumprimento da ordem em caso de flagrante por crime permanente. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA DURANTE O PERÍODO NOTURNO. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 44 DA LEI 11.343/07. VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno. II. Verificando-se a existência de flagrante delito, mostra-se irrelevante o fato de os policiais estarem munidos de mandado de busca e apreensão, sendo inviável o reconhecimento de nulidade nos termos do art. 245 do CPP, por suposta inobservância das formalidade legais exigidas para o cumprimento da aludida ordem judicial ... Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 183.110/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 17/08/2011)

Na questão de fundo, o pedido é procedente.

O réu Vinicius Sabá Kelse foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, deste modo, o pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada por Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01 e 10), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 06) e Laudo de Constatação Provisório (fls. 58-60) e Laudo Definitivo (fls. 177-179).

A autoria delitiva por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 e 10), local de apreensão dos entorpecentes (residência do réu), assim como pelo depoimento das testemunhas.

Testemunha Renan afirmou:

Recebemos a denúncia de que elai ocorria tráfico de drogas. Fomos até lá e vimos a residência fechada. Pedimos ao proprietário e o Vinicius perguntou o que era. Ele retornou para pegar a chave do portão. Meu parceiro estava no portão lateral e nesse momento ele visualizou alguém arremessando uma caixa. Quando o Vinicius retornou perguntamos sobre o conteúdo e ele disse que era entorpecente e dinheiro. Pedimos ao vizinho para entrarmos e pegar a caixa. No conteúdo tinha maconha e dinheiro. Perguntado ao Vinicius ele tinha que não possuía mais. Ele disse que recebeu a droga de um rapaz que tinha sido preso antes. Ele disse que estava revendendo. Falaram do Vincius, descrição física. A descrição correspondia. Meu colega recuperou a caixa. Não lembro ao certo a quantidade. Dinheiro em notas diversas. Estava a descrição do local e do Vinicius. Se me recordo bem foi ele mesmo que atendeu a equipe. Meu colega viu. Eu e uma equipe de apoio.

Testemunha Anderson:

Estávamos aqui na CIA Militar e recebemos uma denúncia de tráfico, perto da Benfica. Montamos as equipes para a averiguação. Era uma casa com portão de chapa na frente. Parte da equipe que participou bateu no portão. Visualizaram uma certa movimentação no fundo da casa. Eu fiquei na lateral, no portão da casa vizinha. A intenção minha era para ver tinha alguém fugindo pelos fundos. Em dado momento, enquanto alguém estava atendendo, eu visualizei alguém jogando um objeto no corredor da casa do vizinho. O réu presente atendeu a equipe, foi indagado do que se tratava, ele colaborou com o serviço. Falou que realmente tinha dispensado uma caixinha com drogas dentro. Tinha um pouco de dinheiro também, diante disso, fizemos o contato com o rapaz que morava na casa vizinha. Ele abriu o portão, consegui pegar o objeto com um pouco de droga. O rapaz que foi preso disse que adquiriu de um rapaz que prendemos antes. Disse que estava comercializando a droga porque estava com dívida, algo desse gênero. Não era uma quantidade expressiva, acredito que ele iria fracionar. Não era muito dinheiro. Ele disse que já havia vendido parte da droga. Ele disse que já tinha usado o dinheiro com as dívidas. Tinha um pessoal no fundo, porém o pessoal da ocorrência vislumbrou que não tinham nada com a ocorrência, porque o réu assumiu a posse da droga. A gente não ia ficar inventando história, porque do jeito que foi narrada foi o que a gente vislumbrou. Tinha um pessoal que morava no fundo, tinha outra residência no fundo da casa, se não me falha a memória era parente desse rapaz. Uma senhora de idade, ficou até assustada. O réu confessou de imediato o que houve, que foi a dispersão da droga que ele jogou no vizinho. A comercialização do entorpecente. Que me recordo, talvez alguns policiais fizeram uma vistoria mais superficial, tendo em vista que o fruto da denúncia foi voltada para o lado positivo com a prisão. Para mim, particularmente, eu soube de que naquelas imediações estava havendo, não especificadamente na casa em si, mas no trecho, com a denúncia desse próprio dia, somente confirmou o que eu já havia pego essas informações. Eu não conhecia o local em si. Ele havia dito para nós, em conversa informal, que adquiriu do rapaz preso em data anterior. Ele pegou a droga um dia antes da prisão desse rapaz. Agora como ele conseguiu contato, acredito que parte desse contato poderia estar no celular apreendido.

O réu negou a prática do crime:

Tenho 19. Sou usuário de maconha. Tem uns dois anos. De menor. 157. Peguei oito meses de fundação. Tinha 16 para 17 anos. Estou trabalhando. Sou atendente em autopeças. Ganho R\$ 1.200,00. Não terminei, quando saí da fundação tive vários problemas. Estou esperando a vaga. Mora com minha avó. Um primo meu. Sou inocente. No dia que eles desceram em casa eu acabei jogando a caixa para o vizinho. A droga era para meu consumo. O dinheiro era meu. A droga era para meu uso próprio. Eu não joguei o dinheiro, estava na gaveta debaixo das roupas. Eles acharam quando revistaram meu quarto. A única coisa que falei foi que tinha pego desse rapaz, eu

fiquei com muito medo porque eles falaram que iam prender minha mãe e minha avó. Não falei. Fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo antes, acabei não pensando bem. Foi uma pressão muito grande, minha mãe algemada. Meus irmãos chorando. O pessoal no fundo algemado. Sim, minha mãe, meu primo, e os amigos dele. Tinha meu primo e mais três amigos. Eu não vi. Todos algemados. Me levaram para meu quarto, falaram que iam me agredir, prender todo mundo, eu fiquei com muito medo. Aconteceu isso na frente da minha mãe. Isso tudo não aconteceu (tortura e abuso de autoridade). Não teve isso. Pessoalmente comprar. A todo momento eu falei que era usuário.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência em que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia. Tratando de tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo a ré praticado os verbos "preparar, vender, ter em depósito, guardar". É o sentir da jurisprudência:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp 604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integra organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, tais como a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, sendo descabida a desclassificação. O intuito de traficância está demonstrado por meio da quantidade de entorpecentes

apreendidos, em residência do réu, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa maneira, não há de se falar em absolvição do réu por não haver elementos suficientes e necessários para uma condenação. Assim também, incabível a desclassificação para usuário, pois o conjunto probatório dos autos torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto. É o sentir da jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça: Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível. (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273).

E ainda:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INCABÍVEL. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DO ART. 33 DA MESMA LEI. RATIFICADO O MÉRITO DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Quando as peculiaridades da casuística, local da ação, quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida tornam indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto, resta incabível o acolhimento do pleito desclassificatório pelo Julgador. Recurso conhecido e não provido. (Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade, Número do Processo: 0502091-15.2016.8.05.0039, Relator (a): Eduarda de Lima Vidal, Seção Criminal, Publicado em: 19/02/2018).

Portanto, havendo subsunção ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a condenação do réu é a medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são neutras e que o réu é primário, tratando-se de neófito na mercancia de entorpecentes. Assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa. Deixo de efetuar a valorização em razão da Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Cabível a concessão do benefício do §4º, devendo ser aplicada a fração de 1/6. Nota-se que o réu foi recentemente liberado da fundação casa pela prática de ato infracional praticado mediante violência/grave ameaça (equiparado a roubo - fls. 29-30), situação de acentuada reprovação em sua conduta.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa.

Não se cogita da substituição por penas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal), assim como incabível a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (artigo 77 do Código Penal) em virtude da quantidade da pena.

Considerando a quantidade de pena aplicada fixo como regime inicial para cumprimento de pena o regime semiaberto.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de VINICIUS SABÁ KELSE, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,, e ao pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

Concedo ao réu o recurso em liberdade.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes, e o perdimento de bens e valores à União, em razão da ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno a ré ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, e expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

Jandira, 09/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA